

1501285-33.2022.8.26.0664
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI
Comarca: Votuporanga
Foro: Foro de Votuporanga
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/08/2022
...

Pende a controvérsia no tocante à caracterização do tráfico ou uso, teses sustentadas pelo Ministério Público e pela Defesa, respectivamente.

E nesse aspecto, percebe-se, claramente, que os depoimentos dos policiais são coesos e descrevem com pormenores a atuação do réu no tráfico de drogas e a apreensão das substâncias em sua posse e em sua residência, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Votuporanga
Foro de Votuporanga
1ª Vara Criminal
Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501285-33.2022.8.26.0664 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501285-33.2022.8.26.0664
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2115876/2022 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 24620063 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2115876 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2115876 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL MAGRINI DE JESUS (menor de 21 anos)
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face de GABRIEL MAGRINI DE JESUS, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, consoante seguintes fatos narrados na denúncia (fls. 112/114):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de abril de 2022, por

volta de 22h30, na Avenida José Espinosa com a Rua Augusto Zanforlin, e na Rua Euflazina Marciana da Silva, nº 254, Valentim Gentil, nesta comarca, GABRIEL MAGRINI DE JESUS, qualificado a fls. 21, e fotografado a fls. 33/36, trazia consigo e guardava, com o propósito de tráfico, a massa líquida de 238,82g (duzentos e trinta e oito gramas e oitenta e dois centigramas) da substância entorpecentes vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados e 17 (dezessete) porções individualizadas e mais duas porções maiores, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 15/17, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 97/99, e fotografia de fls. 13.

A denúncia foi recebida no dia 07 de julho de 2022 (fls. 139/141).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, que, ainda, autorizou a destruição da droga, reservada amostra a contraprova, consoante fls. 46/49.

Citado (fls. 136) o acusado apresentou defesa prévia (fls. 124/127), por meio de defensora nomeada (fls. 40).

Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 139/141).

Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado. As partes se manifestaram em debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

Afasto a preliminar de nulidade da entrevista informal realizada pelos policiais militares no momento do flagrante. Nos termos dos artigos 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, e 186 do Código de Processo Penal, o acusado tem direito ao silêncio ou à não autoincriminação e, ao ser interrogado em qualquer fase processual, pode se calar acerca dos fatos criminosos ou negar a autoria, sem que isso enseje apenação criminal ou mesmo valorização negativa dessas declarações pelo juiz, que poderá, no máximo, desconsiderá-las quando do cotejo com os demais elementos probatórios colacionados. No caso em apreço, a entrevista policial no momento do flagrante não constitui interrogatório extrajudicial e, ademais, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo.

A propósito: AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; e AgRg no HC 472.683/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020.

Além disso, não se tem notícia da ocorrência de constrangimento ilegal na entrevista policial realizada por ocasião do flagrante e eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal (HC 586.321/AP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 28/08/2020).

De seu turno, a matéria arguida pela defesa, quanto à busca domiciliar na residência sem mandado judicial ou prévia autorização, fica rejeitada, reconhecendo-se que as provas apreendidas a partir do ingresso policial na residência são consideradas lícitas, pois evidenciada a situação de flagrância, justificador da entrada dos policiais, sendo dispensável qualquer ordem judicial. Ademais, embora a casa seja o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se praticam.

Em se tratando de flagrante delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar, pois o próprio texto constitucional (art. 5º, inciso XI, da Carta Magna) admite que se penetre na casa mesmo à noite, e sem o consentimento do morador, em caso de flagrante delito, sendo certo que, consistindo o tráfico em infração de natureza permanente, afigura-se prescindível a prévia autorização judicial para ingresso na morada do investigado. A garantia constitucional não é absoluta.

Não bastasse, ficou bem comprovado que o réu foi abordado após os policiais visualizarem pegando algo e perto de um veículo e, ao avistar a polícia, o réu saiu e dispensou porções e celular, aí foi abordado e indicou o local em que havia dispensado droga. Isso foi confessado pelo réu. Também ficou claro que os policiais responsáveis pela abordagem são de fora da cidade, não conheciam o réu e o endereço do réu foi indicado pelo mesmo. Ora, ao indicar o endereço e acompanhar os policiais até lá o réu autorizou a conduta dos policiais e ainda indicou o vaso no qual havia escondido a droga. A busca domiciliar não teve apoio do canil e dificilmente os policiais teriam localizado a droga sem a informação do réu. Por fim, anoto que a matéria foi recentemente objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que cassou a decisão proferida anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, cujas razões adoto, aqui, como razão de decidir, para afastamento dessa preliminar: “De acordo com sólida orientação doutrinária e jurisprudencial há muito firmada, o tráfico de drogas é crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso no imóvel residencial ou congêneres, em qualquer dia e horário, independentemente de mandado judicial, na formado disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A propósito: “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui delito permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, no caso, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Precedente.” (Superior Tribunal de Justiça, HC Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 11ª Câmara – Seção Criminal Apelação Criminal nº 1500279-55.2020.8.26.0439 - Pereira Barreto 5 451502/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

No caso em tela, ademais, conforme depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante (fls. 02/03), a busca na residência do acusado foi autorizada por sua genitora (Eliete Magrini) e, portanto, houve autorização prévia. Havia, ainda, indícios suficientes do envolvimento do réu no tráfico, conforme detalhado no depoimento dos policiais, abaixo analisados, observando que, antes da entrada na residência do réu, já tinha sido localizado 17 porções de maconha com o acusado. No mérito, de rigor a procedência da presente ação penal. Há nos autos prova da materialidade e de autoria, não obstante as ponderações da combativa defesa.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), nota de culpa (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), fotografias (fls. 13), laudo de constatação (fls. 15/17), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 97/99), laudo de exame pericial nos objetos apreendidos (faca, balança de precisão e carteira – fls. 191/196), laudo de exame pericial no celular apreendido (fls. 197/200 e fls. 202/261), bem como demais provas colhidas.

O laudo de exame químico-toxicológico (fls. 97/99) constatou que a substância analisada revelou resultado POSITIVO para TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constantes na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

A autoria, por seu turno, é certa e pode ser atribuída ao réu.

Com efeito, restou comprovado, diante dos depoimentos das testemunhas, a prática do delito imputado ao réu. Vejamos.

Na fase inquisitiva, o policial militar Coutinho (fls. 02) disse que realizava patrulhamento na Festa de Peão com seu colega de farda, quando avistaram um

indivíduo entregando entorpecente para outrem. Tentaram abordar ambos, mas apenas conseguiram abordar o possível vendedor, já que o possível comprador se evadiu do local. Em busca pessoal, localizaram 17 porções de maconha, além da quantia de R\$ 292,00 e um telefone celular. O indivíduo confessou a prática do tráfico, informando que venderia cada porção por R\$10,00 e, ainda informou que, em sua residência, tinha mais maconha e uma balança de precisão. Diante disso, deram voz de prisão ao acusado e se dirigiram à sua residência, onde tiveram a autorização da genitora do acusado para realizarem a busca e localizaram uma balança, uma faca, uma porção média e uma porção grande de maconha. No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Santana (fls. 03).

Em juízo, o policial militar Hebert disse que estava em patrulhamento na festa do Peão de Valentim Gentil quando avistou o réu desembalando algo, observou mais um tempo e, então, resolveu fazer a abordagem, ele tentou fugir e, na fuga, dispensou algo; com a abordagem, localizaram uma porção de maconha em poder dele, que indicou o local que havia dispensado as outras porções e um celular; ele acabou confessando que tinha adquirido a maconha pouco tempo antes e autorizou, inclusive indicou, revista em sua casa, onde localizaram mais droga. A mãe se mostrou surpresa com a situação. Os familiares acompanharam as buscas e foi localizada maconha enterrada em um vaso, ele que indicou, e mais um pouco no quarto, além de balança de precisão. A festa do Peão ocorria em um recinto, e o réu foi abordado do lado de fora da festa, o viram descer do veículo e organizar as porções que seriam vendidas na festa. Não lembra se tinha dinheiro. As expressões cha, comprar o verde, estralando, são utilizadas na linguagem do tráfico. Não conhecia o réu até então, pois atua em Votuporanga e foi trabalhar em Valentim no dia por conta da Festa do Peão, daí os policiais de lá informaram que ele era conhecido. Pelo que lembra, o réu estava sozinho por ocasião da abordagem, não lembra de tê-lo visto passar. Corroborou sua versão o depoimento do PM Santana, afirmando que faziam reforço na segurança e, nas proximidades da festa, avistaram o réu com um pacote e um veículo nas proximidades, tentaram abordar, ele correu, mas foi abordado e ele admitiu que venderia a droga na festa; ele não tinha documento e se deslocaram até a casa dele, a mãe aparentou surpresa com a abordagem, e ele indicou onde estava a droga. Não avistaram usuário com ele nas proximidades da Festa. O réu não indicou o fornecedor da droga, admitiu ter adquirido a droga picado para vender no evento. Não conhecia o réu, pois ele é de Valentim e foi seu primeiro contato com ele, não trabalha lá. A mãe do réu, Eliete Magrini, foi ouvida como informante e disse que, no dia, levou Gabriel ao evento e o deixou lá. Sabe que ele é usuário há uns 5 anos. Os policiais encontraram maconha na sua casa, ele tinha enterrado num vaso, duzentas e poucas gramas, ele tinha recebido o pagamento e usava para o mês todo, e como a droga não era boa, ele enterrou para devolver. Gabriel é solteiro, sempre morou em sua companhia, e trabalhava ajudando a depoente, uma espécie de terceirizado no serviço de botão. Ele foi internado na fundação por tráfico, ficou rebelde, mas quando saiu viu que isso não é vida, voltou totalmente diferente, e depois teve recaída pela mudança do pai para os EUA.

O padrasto do réu, Fernando Gomes Da Silva, atestou a boa conduta do réu, afirmando que ele sempre foi bom filho; no dia, ele tinha ido à festa do Peão e logo voltou com a polícia. Os policiais não pediram autorização para ingresso na residência. Na fase inquisitiva, o réu (fls. 04) permaneceu em silêncio.

Interrogado judicialmente, o réu confessou a prática delitiva. Disse que usa maconha há mais de 5 anos. Comprou maconha, mas não gostou da qualidade, desceu para o rodeio e comprou uma quantidade lá, aí ficou surpreso com os policiais da rocam, assustou e dispensou a droga, mas quando abordado indicou o local que tinha dispensado a droga, que foi localizada. Tinha acabado de comprar a droga, 17 porções, essa quantidade porque a qualidade era maior que a sua; pagou R\$ 400,00 pelos 250 g e R\$ 160,00 pelas 17 porções; ganhava R\$ 600,00 por quinzena. Quanto ao dinheiro em seu poder, R\$ 292,00, tinha recebido da sua mãe da fábrica. O celular era de uma amiga da sua ex; saíram juntos, brigou com a ex, acabou achando no veículo, isso cerca de um mês antes da prisão. Não conhecia os policiais.

A prova colhida sob o crivo do contraditório corrobora a confirmação do réu quanto à droga apreendida, fornecendo certeza de autoria.

Pende a controvérsia no tocante à caracterização do tráfico ou uso, teses sustentadas pelo Ministério Público e pela Defesa, respectivamente.

E nesse aspecto, percebe-se, claramente, que os depoimentos dos policiais são coesos e descrevem com pormenores a atuação do réu no tráfico de drogas e a apreensão das substâncias em sua posse e em sua residência, em consonância com os demais elementos colhidos.

Conforme entendimento corrente, o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, tratando-se de prova apta a amparar a condenação, sobretudo no presente caso, em que não paira, de forma fundada e concreta, qualquer suspeita de parcialidade ou inidoneidade.

Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os depoimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais. Nesse sentido: "Com efeito, a palavra de policiais deve ser tida como verdadeira se não demonstrado no curso da persecução penal qualquer contradição relevante ou de elementos que indiquem relações inamistosas entre estes e o acusado em juízo, porque presunção "jûris tantum" de veracidade. Note-se que os participantes da operação não ofertaram nenhum ponto obscuro ou nebuloso que se faça presumir estejam criando estratagemas para incriminar indistintamente inocente. Por consequência, infere-se, com a necessária segurança, que nada recomenda a colocação da pecha da suspeição nesses depoimentos. Agiram de maneira escorreita e sob o manto da legalidade, merecendo integral credibilidade seus depoimentos." (Apelação criminal nº 993.07.048506-0 - São Paulo - 4º Câmara de Direito Criminal - Relator Paulo Rossi - registrada em 21/07/2010).

De seu turno, a forma de acondicionamento da droga, ou seja, em porções pequenas, embaladas individualmente, também indica a posição do réu de fornecedor na cadeia de comercialização do produto ilícito, além do armazenamento de mais droga em sua casa, para preparo de outras porções.

A posse de numerário (R\$ 292,00) sem prova de desempenho de atividade lícita remunerada também aponta para o tráfico, além dos petrechos encontrados na residência, como a faca, balança de precisão e, ainda, porções médias e grandes de maconha para serem fracionadas.

Assim, as circunstâncias da prisão, a quantidade de droga apreendida, forma de armazenamento, bem como a nítida situação de tráfico demonstram a traficância. Os elementos de prova permitem responsabilizar o réu pelo tráfico, afastando-se a tese de fragilidade do conjunto probatório, e ademais, razão alguma haveria para que os policiais incriminarem os réus de forma leviana.

Da mesma forma não há que se cogitar em desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, já que o denunciado em nenhum momento disse ser usuário de entorpecentes. E ainda que fosse, tal circunstância (ser usuário), de maneira alguma, afasta a prática da traficância ou enseja a eventual desclassificação do tipo penal para o de porte de entorpecentes para consumo pessoal.

A versão do réu, de que tinha comprado mais de 200 gramas de maconha, mas não gostou da qualidade e, por isso, enterrou num vaso para devolver e saiu para comprar mais droga na ocasião, não se sustenta. O réu declarou que ganhava cerca de R\$ 600,00 por quinzena. Isso não foi comprovado. E ainda que o fosse, a quantia é incompatível com tamanha quantidade de droga adquirida em tão pouco tempo. Sendo usuário, e em fase de uso intenso após a mudança do pai para os EUA, como declarou a mãe do réu, não faz sentido deixar de usar maconha por não gostar da qualidade. Ficou demonstrado que a mãe e padrasto do réu tinham ciência de sua qualidade de usuário, inclusive a mãe disse que deixava que fumasse na casa para evitar que ficasse na rua. Ora, o réu não tinha motivos para ter enterrado a droga.

Não bastasse, as conversas no celular da amiga da ex namorada, que o réu admitiu ter ficado em seu poder por mais ou menos um mês antes dos fatos. A análise das conversas a fls. 248/253 revela a traficância, com negociação do valor, entrega, inclusive informações de que estaria no rodeio.

Desta forma, de rigor a condenação do réu pela prática dos crimes previstos na denúncia.

Caracterizada a prática do delito, passo à dosimetria da pena, observando a Folha de antecedentes e certidões de fls. 26/27, 41/45 e 116/119.

Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (vide fls. 26/27, 41/45 e 116/119), ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, deixo de atenuar a pena pela menoridade, em razão de estar no patamar mínimo legal, observando, no tocante à confissão, que o réu assumiu a posse da droga, mas negou a traficância. Aplica-se a Súmula 231 do STJ, mantendo a pena. Já na terceira fase, não é caso de aplicação do privilégio. Em que pese a primariedade do réu, a quantidade de droga é expressiva para a pequena cidade de Valentim Gentil, com aproximadamente 13.000 habitantes, e o benefício exige bons antecedentes e que o agente não se dedique à atividade criminosa, requisitos não preenchidos pelo réu.

De fato, o réu declarou ter cumprido medida sócio educativa de internação por seis meses, o que foi confirmado pela mãe e pelo padrasto, o que não é compatível com bons antecedentes, observando que tem apenas 19 anos e já se envolveu em outro tráfico.

Observo que a aplicação de medida sócio educativa de internação, embora não se preste ao reconhecimento de maus antecedentes, e muito menos de reincidência, por outro lado não podem ser ignorada para aferir a sua personalidade, bem demonstrando que dedica intensa exclusivamente, de há muito, ao crime, inclusive à narcotraficância. Nesse sentido, Apelação nº 1500074-67.2021.8.26.0608, TJSP, julgado em 11/03/2022.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade aplicadas por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta.

Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu GABRIEL MAGRINI DE JESUS à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, unidade mínima, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (primário e menor de 21 anos). Custas pelo réu, ressalvada a gratuidade (fls. 139).

O réu respondeu ao processo preso e persistem os requisitos da custódia cautelar, pelo que não poderá recorrer em liberdade, recomendando-se-o na prisão em que se encontra e, em caso de recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória.

Autorizo, outrossim, a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Por fim, quanto ao numerário apreendido, decreto o perdimento em favor da União, providenciando-se oportunamente o encaminhamento.

Observo que o celular já foi liberado (fls. 266).

Com o trânsito em julgado, providencie-se: (i) expedição de guia definitiva para o cumprimento da pena; (ii) intimação dos réus para pagamento das custas, se não beneficiário da gratuidade; (iii) cálculo da pena de multa e expedição de certidão de sentença, abrindo-se vista ao MP, cumprindo-se, no mais, o disposto no art. 479 e/ou 480 e §§ das NSCGJ; (iv) comunicação à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; (v) expedição de ofício ao IIRGD e o

instrumental necessário ao integral cumprimento da sentença, com lançamento das movimentações pertinentes para arquivamento.
Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência, saindo os presentes intimados.
Cumpra-se.
Votuporanga, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA